

1502351-59.2021.8.26.0510

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502351-59.2021.8.26.0510 -

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502351-59.2021.8.26.0510 - 2021/000478

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS GABRIEL FERREIRA CRESCIONE

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

CARLOS GABRIEL FERREIRA CRESCIONE, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 19 de julho de 2021, por volta das 18h28min, na Rua Vinte e Cinco Be, Bairro do Estádio, nesta Comarca, guardava, tinha em depósito e trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que se destinavam ao fornecimento a terceiros, venda e tráfico, consistentes em 111 (cento e onze) microtubos do tipo eppendorf, contendo a substância cocaína, pesando 114,3 gramas, bem como a quantia de R\$45,00 (quarenta e cinco reais), conforme boletim de ocorrência de fls. 18/19, auto de exibição e apreensão (fls. 20), laudo pericial nº 235.412/2021 (fls. 23/25) e laudo pericial nº 237.160/2021 (fls. 76/78 - exame químico toxicológico - definitivo).

Regularmente notificado, seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do acusado, sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 19 de outubro de 2021. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, com posterior

interrogatório do acusado.

Em alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena-base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional inicial aberto, com imposição da pena de perdimento em relação aos valores apreendidos, porque decorrentes da atividade ilícita.

Já o ilustre Defensor, sustentando insuficiente a prova produzida, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, operando-se em seguida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional inicial aberto.

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, assim porque trazia consigo, e ainda guardava e tinha em depósito, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conquanto incontroversa, a materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 76/78, com resultado positivo para cocaína.

Controverte-se sobre a posse e a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Ouvido em Juízo, o acusado negou a prática do delito que lhe é atribuído na denúncia, afirmando que na ocasião dos fatos, após reunir algum numerário em razão de auxílio ao tio, que é pintor, como também em decorrência da venda de material reciclável, dirigiu-se a um ponto de venda de entorpecente, porquanto usuário, onde adquiriu uma porção de crack. Seguiu então para o local indicado na denúncia, denominado de "beco", local onde imaginava poder comprar maconha, quando foi abordado por policiais militares, momentos antes dispensando ao solo aquela porção de crack. Embora ostente registro pela prática de igual delito, afirmou tratar-se de usuário, com indicação de tratamento anterior em clínica especializada.

Todavia, a versão deduzida pelo acusado, além de não contar com nenhum apoio probatório, foi contrariada pela prova produzida.

De fato, os Policiais Militares ouvidos em juízo, reiterando o que exposto contemporaneamente aos fatos, de forma clara e minudente, esclareceram que na ocasião estavam em patrulhamento em local de intenso tráfico de entorpecentes, quando avistaram o acusado deixando uma viela, dando-se pressa quando notou a aproximação da guarnição. Diante destas circunstâncias, foi em seguida abordado, apreendendo-se em poder dele, junto à cintura, dois invólucros plásticos contendo no total cinquenta e uma porções de cocaína, com ele também se encontrando a quantia de quarenta e quatro reais em dinheiro e um real em moeda.

Ainda segundo os exposto pelos Policiais Militares, na referida viela, sob um entulho, localizaram ainda outras sessenta porções de cocaína, idênticas àquelas que estavam em poder do acusado.

Como se tem consagrado, à míngua de elemento que demonstre efetivamente algum abuso, não há de se desmerecer o depoimento dos policiais militares envolvidos nas diligências. A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54). Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação

de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Deste modo, evidenciada não apenas a posse do entorpecente, notadamente aquele apreendido em poder do acusado, como também revelando as circunstâncias a destinação mercantil, seja porque se tratava de local já conhecido pela realização do comércio ilícito -- não havendo nenhuma razão justificada de que por lá pudesse estar um usuário com cinquenta porções de cocaína --, seja pela movimentação do acusado, que procurou evitar a abordagem, o que não se mostra compatível com quem estaria tão somente com uma porção de crack, que sequer foi objeto da apreensão. Assim, todos esses elementos probatórios permitem seguro juízo de convicção sobre a imputação inicial, devendo incidir sobre a quantia em dinheiro apreendida a pena de perdimento, já que não comprovada a alegação da origem lícita.

Isto considerando, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais e judiciais favoráveis, não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, possível seja fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, deve a pena-base cominada ser reduzida em função do que disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Este dispositivo legal cuida da possibilidade de operar-se a redução da pena, quando se tratar de réu primário, de bons antecedentes, não integrante de organização criminosa e que não esteja dedicado ao comércio ilícito.

O acusado é primário, não ostenta condenação criminal anterior, não podendo afastar a causa de diminuição o registro criminal ostentado, seja em razão do princípio da não culpabilidade, seja porque de per si não possibilita a conclusão segura sobre eventual dedicação à atividade ilícita, de tal modo que, também em função da pouca quantidade de entorpecente, deve a pena base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 caput e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos

normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo".

Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016).

Acrescentou-se que, nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06).

Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo.

Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda. Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, caput, c.c. §4º da Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado CARLOS GABRIEL FERREIRA CRESCIONE à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, como também de pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo, operando-se ainda o perdimento da quantia apreendida em favor da União, porque decorrente da ação ilícita, nos termos do disposto no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Diante da pena cominada, fica revogada a prisão preventiva, facultando-se a interposição de recurso em liberdade, com expedição de alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA